KINX2003022437

就業規則의 不利益變更이 有效하기 위한 諸般事情에 관하여

辯護士 張 元 燦

事件의 表示
[대법원 2002. 5. 24. 선고 2002다8131 판결]

〈 目 次 〉

Ⅰ. 事實關係
Ⅱ. 抗訴審의 判斷개요
Ⅲ. 大法院의 判斷개요
Ⅳ. 就業規則變更의 合理性判決理由
Ⅴ. 就業規則 變更節次法條項의 沿革
Ⅵ. 日本判例의 沿革
Ⅶ. 舊法下의 大法院判例
Ⅷ. 新法下의 大法院判例
Ⅸ. 서울地方辯護士會의 判例硏究資料
Ⅹ. 反省 · 討議를 요하는 側面

Ⅰ. 사실관계

(1) 원고들 2인은 1968. 피고(財團法人 韓國衣類試驗硏究院)에 입하여 근속하다가 1996. 퇴사하였다.

(2) 피고 硏究院은 1980. 7. 9.경 감독기관인 공업진흥청장으로부터 임직원들에 대한 근속연수에 따른 退職金 支給率 調整案을 시달받고 이에 따라 퇴직금 지급률을 하향조정하여 1980. 7. 1.자로 소급하여 시행하는 내용으로 급여규정을 개정하였고 (이하 '1차

개정'이라 한다), 1981. 1. 23.경 다시 공업진흥청장으로부터 임직원들의 退職金 支給率 引下案을 시달받고, 1981. 1. 1.자로 소급하여 이를 하향조정하는 내용으로 급여규정을 개정하였다.(이하 '2차 개정'이라 한다)

(3) 퇴직금산정의 基準給與額에 관하여, 1차 개정전 급여규정에서는 최근 3월간의 급여총액(상여금 포함)을 총일수로 나눈 월액으로 규정하였으나, 1차 개정에서는 기본급(본봉 · 직책수당 · 근속수당) 및 月平均賞與金으로 정하였다가, 2차 개정된 급여규정 제19조 제2항에서는 現行 規定과 같이 "직원의 퇴직금 산정시 기준급여는 基本給, 諸手當(매월 全 직원에게 月定額으로 지급하는 수당 : 특수수당, 시간외수당, 휴일수당, 월차수당, 연차수당) 및 賞與金을 합산한 금액으로 한다."고 규정하고 있다.

(4) 피고 硏究院은 퇴직금을 산정함에 있어서 원고들 퇴직 당시 기본급에 시간외수당, 월차수당, 중식비의 퇴직 전 3개월 평균치, 연차수당의 1개월분 및 1년간의 월평균 상여금을 합한 금액을 基準給與로 하고, 근속기간에 따른 支給率에 관하여는 2차 개정된 급여규정 附則에 따라 입사일로부터 1980. 6. 30.까지는 1차개정 전 규정에서 정한 지급률을, 1980. 7. 1.부터 1980. 12. 31.까지는 1차 개정된 규정이 정한 지급률을, 1981. 1. 1.부터 퇴직시까지는 2차 개정된 규정이 정한 지급률을 각 적용하였다.

Ⅱ. 抗訴審의 判斷개요

원심은 위2차 개정된 급여규정(= 現行 給與規定) 제19조 제2항의 기준급여에 포함되는 諸 手當으로 열거된 것은 例示的인 것으로 보고 피고 硏究院이 매월 全 직원들에게 月定額으로 지급하는 수당은 基準給與에 포함되어야 됨을 전제로,

1) 특별상여금, 장기근속수당, 체력단련비, 효도휴가비, 가계보조금, 출퇴근 보조금은 매월 全직원에게 月定額으로 지급된 것이어서 모두 기준급여에 포함되어야하는 한편,

(2) 特別成果給과 자녀학비보조수당은 기준급여에 포함될 수 없다고 판단하였다.

(3) 特別賞與金에 대하여는 급여규정 제19조 제6항(="定期賞與金 以外의 급여는 퇴직금산정기준에 포함되지 아니한다.)이 근로자측의 同意下에 新設되었다는 점에 대한 주장 · 입증이 없다면서 특별상여금을 퇴직금산정기준에 포함시켰다.

Ⅲ. 大法院의 判斷개요

가. 피고(使用者)의 上告理由에 대한 판단

피고 硏究院은 원심판결에 전면 불복하였는데, 이에 대한 대법원의 판단은 아래와 같다.

(1) 위 2차 개정된 급여규정(※ 現行) 제19조 제2항에서 월정액수당으로 列擧되지 아니한 수당들 가운데, 장기근속수당 · 가계보조금 · 출퇴근보조금은 每月全職員들에게 月定額으로 지급된 것이어서 이들을 퇴직금산정기준급여에 포함시킨 원심판단은 정당하나,

(2) 체력단련비는 기본급의 200%를 연 2~3회 나누어 지급하였고, 효도휴가비는 연 2회 설과 추석이 있는 달에 지급하였는 바, 이는 每月 月定額으로 지급하는 수당에 해당한다고 볼 수 없으므로 이들을 위 기준급여에 포함시킨 원심판단은 잘못이다.(심리미진 · 사실오인 등)

(3) 급여규정 제19조 제6항(= "定期賞與金 以外의 급여는 퇴직금산정기준에 포함되지 아니한다.")이 근로자측의 同意下에 新設되었다는 점에 대한 주장 · 입증이 없다는 이유로 特別賞與金에 대한 위 규정의 적용주장(피고주장)을 배척한 원심판단은 잘못이다.(심리미진 · 사실오인 등)
※ 이 점에 대한 判決理由 설시부분은 다음 項으로 자리를 넓혀 싣기로 한다.

나. 원고(勞動者)의 上告理由에 대한 판단(棄却)

원고는 원심이 배척한 2개 수당(특별성과금, 자녀학비보조수당)에 대하여 불복하였으나, 아래와 같이 모두 기각당하였다.

(1) 상여금이 퇴직금산정기초에 산입될 수 있는지 여부는 退職當時를 기준으로 판단하여야 한다. 그런데 이 사건의 특별성과금은 원고들이 퇴직할 당시를 기준으로 할 때에는 向後 계속 지급될지 여부가 不確實한 상태였다 할 것이어서, 그것이 賃金으로서의 性格을 가진다고 보기 어려우므로, 이를 퇴직금산정기준급여에서 제외시킨 원심판단은 정당하다.

(2) 자녀학비보조수당은 급여규정에서 중 · 고등학교에 재학중인 子女가 있는 職員에 대하여 예산의 범위안에서 分期別로 지급하도록 규정되어 있는 바, 이는 每月 全職員에게 月定額으로 지급하는 수당에 해당하지 않으므로, 이를 퇴직금산정기준급여에서 제외시킨

원심판단은 정당하다.

Ⅳ. 就業規則의 不利益 更의 合理性 판시부분

원심이 원용한 제1심판결은 給與規程 제19조 제6항이 "定期賞與金 以外의 급여는 퇴직금 산정기준에 포함되지 아니한다."고 규정하고 있으므로 定期賞與金이 아닌 特別賞與金은 기준급여에서 除外되어야 한다는 피고의 주장에 대하여 그 채용한 증거에 의하여 위 규정은 1990. 12. 13. 급여규정개정에 관한 勞使協議 당시까지는 존재하지 않았던 사실이 인정되므로 1990. 12. 13. 노사협의 이후 新設된 것으로 추인되는데, 이는 근로자에게 不利하게 變更된 것으로서 피고가 위 규정의 新設에 대하여 근로자의 집단적 의사결정 방법에 의한 同意가 있다는 점에 대한 주장 · 입증이 없는 이 사건에서 원고들에게 대하여는 위 규정이 적용되지 않는다는 이유로 피고의 위 주장을 배척하였다.

(1) 사용자가 일방적으로 새로운 취업규칙의 작성 · 변경을 통하여 근로자가 가지고 있는 旣得의 權利나 利益을 박탈하여 不利益한 근로조건을 부과하는것은 原則的으로 허용되지 아니한다고 할 것이나,

당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 必要性 및 內容의 兩面에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 如前히 당해 조항의 法的 規範性을 是認할 수 있을 정도로 社會通念上 合理性이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정 방법에 의한 同意가 없다는 理由만으로 그 적용을 否定할 수는 없다고 할 것이고,

한편 여기에서 말하는 社會通念上 合理性의 有無는,

① 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 될 不利益의 程度,
② 사용자측의 變更必要性의 內容과 程度,
③ 更變後의 취업규칙 내용의 相當性, 代償措置 등 관련된 다른 근로조건의 改善狀況,
④ 노동조합 등과의 交涉經緯 및 노동조합이나 다른 근로자의 對應,
⑤ 同種 事項에 관한 국내의 一般的인 狀況

등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

(2) 기록에 의하여 살펴보면,

① 피고 硏究院의 퇴직금 지급에 있어서 累進率이 지나치게 높아 특별상여금 등을 퇴직금 산정의 기초가 되는 기준급여에서 除外하더라도 勤勞基準法에 의하여 算定된 退職金額數를 훨씬 超過하고 있는 점,

② 피고 硏究院은 공업진흥청 산하기관으로서 定款에 급여규정 등의 제정 및 개폐에 관하여 감독관청인 공업진흥청장에게 報告하도록 되어 있으며,

③ 피고 硏究院의 勞動組合이 1990. 12. 13. 退職金 算定에 관한 급여규정의개정에 合意를 한 바 있고,

④ 피고 硏究院은 그 以後 每年 노동조합과의 賃金協定을 통하여 기본급 등을 引上해 온 사정에 비추어 보면 피고 연구원의 勞動組合이 1990. 12. 13. 勞使協議 以後의 급여규정의 개정에도 관여하였을 것으로 보이는 바,

원심으로서는 급여규정 제19조 제6항의 新設 時期와 經緯에 관하여 審理하여, ① 위 규정 신설의 必要性과 이로 인하여 근로자들이 입게 되는 不利益 程度, ② 이에따른 代償措置와 다른 근로조건의 改善狀況, ③ 노동조합과의 交涉經緯 등을 따져 위 규정의 신설에 있어 社會通念上 合理性이 있는지 여부를 심리하여 보았어야 함에도 노동조합의 同意가 있었다는 주장 입증이 없다는 理由만으로 원고들에 대하여 위 규정의 적용을 부인하였는 바, 이는 審理를 다하지 아니하여 事實을 誤認함으로써 위 급여규정 제19조 제6항의 解釋을 그르친 違法이 있다고 하지 않을 수 없고, 이는 판결에 영향을 미쳤음이 분명하므로, 피고의 상고이유의 주장 중 이를 지적하는 취지의 부분은 理由있다.

Ⅴ. 취업규칙 變更節次 法條項의 沿革

근로기준법은 1953. 5. 10. 制定당시 취업규칙의 작성 · 변경에 대한 節次規定으로서, 사용자는 근로자측의 意見을 聽取하고 그 意見書를 첨부하여 노동관서에 신고하도록 규정하였다. 그 全文은 아래와 같다.(日本의 법조항과 꼭 같다.)

제95조(規則의 作成 · 變更의 節次) ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 勞動組合이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 勤勞者의 過半數를 代表하는 자의 意見을 들어야 한다.

② 사용자는 前條의 규정에 의하여 취업규칙을 申告할 때에는 前項의 意見을 기입한 書面을 첨부하여야 한다.

그 후 1989. 3. 29. 改正法律 제4099호(盧泰愚 대통령 시절)에 이르러서는 아래但書가 신설되었다.

第95條 第1項 중 "過半數를 代表하는 者의 意見을 들어야 한다." 를 "過半數의 의견을 들어야 한다. 다만, 就業規則을 勞動者에게 불이익하게 變更하는 경우에는 그 同意를 얻어야한다."로 한다.

위 단서규정은 既得權의 보호법리를 연상시키는 내용으로서 너무도 當然한 입법조치로 여겨지기 마련이다. 그럼에도 이웃 日本은 그 입법논의조차 없을 정도로 조용한 편이고, 단지 단체협약에서 동의조항을 넣어두는 것이 보편화되어 가고 있다.

Ⅵ. 日本判例의 연혁 : 不利益 更의 合理性 理論

主題의 合理性 法理는 昭和 43년(= 1968) 12. 25. 선고, 最高裁判所 大法廷 판결(秋北버스사건)에서 확립되기 시작하였다. 만 55세 停年制를 일방적으로 도입한 사안에 대하여, "勤勞條件의 集合的處理, 특히 근로조건의 統一的이고도 劃一的인 決定을 前提로 하는 就業規則의 性質"로부터, "당해 규칙조항이 合理的인 것인 한, 근로자가 그 존재나 내용을 알지 못하고 있더라도, 개별적 同意가 없더라도 當然히 그 적용을 받는다."라고 판단하였다.

昭和 63년(= 1988). 2. 16. 선고, 最高裁判所 판결(大曲市 농협사건)은 農協의 合併에 따른 退職金規程變更의 合理性 有無가 쟁점이 되었다. 이 판결은 변경된 취업규칙조항이 合理的이라고 말하려면, 그 필요성 및 내용으로 보아서 근로자가 입는 不利益의 程度를 고려하더라도 여전히 法的規範性을 是認할 수 있을 정도로 必要性이 있고, 賃金이나 退職金에 대하여는 高度의 必要性이 요구된다 할 것인 바, ① 合併에 수반되는 근로조건의 統一的 · 劃一的처리의 필요성, ② 급여조정에 의한 不利益의 輕減, ③ 휴일 · 휴가 등의 有利性 등에 착안하여, 法的 規範性을 是認할 수 있을 정도의 合理性이 있다고 판단하였다.

平成 2년(= 1990). 7. 26. 선고, 大阪高 판결(골드 · 매리타임사건)에서는 轉出規定의 新設과 그에 의거한 전출명령의 효력이 쟁점으로 다투어졌다. 1심은 신설된 전출규정에 합리성을 인정하지 않았으나, 2심에서는 그 合理性을 승인하였다.(다만 人選의 점에서는 권리

남용의 무효라고 결론지었다.)

平成 4년(= 1992). 7. 3. 선고, 最高裁判所判決(제1 소형택시 사건)에서는 택시운전기사의 步合給計算方法의 변경이 쟁점이었다. 이 택시회사의 步合給制度는 운전기사의 운임총수입에서 一定金額(= 足切額)을 控除한 후의 금액에 一定支給率을 곱하는 것인데, 쟁점이 된 변경내용은 足切額 27만円, 支給率 35%이던 것을 택시運賃의 引上認可에 즈음하여 足切額 29만円, 支給率 33%로 변경한 것이었다. 1심, 2심은 그 변경이 不利益變更인 것이고 合理性도 인정되지 않는다고 판단했으나, 최고재판소는 견해를 달리하여 파기환송하였다.

Ⅶ. 舊法下의 大法院 判例 ; 效力發生要件說의 論據

舊 勤勞基準法 제95조 제1항에 但書規定("다만, 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 同意를 얻아야 한다.")이 追加(= 新設)되기 전(1989. 3. 29. 前)에 선고된 대법원 판례를 훑어보면, 退職金規程의 불이익변경에 대해서는, 근로자측의 同意를 받아야만 그 效力은 발생한다는 태도를 엄격하게 固守하는 반면, 停年 기타 人事規程의 불이익변경에 대하여는 柔軟性을 보여왔다.

朴正熙 대통령시절에 累積赤字에 허덕이던 大韓石炭公社에 대하여 경영합리화차원에서 턱없이 높은 퇴직금수준을 하향조정하는 방안으로서 退職金 算定의 기준이 되는 平均賃金算定例規를 개정하여 평균임금산정의 기초가 되는 賃金의 범위 중에 賞與金을 除外한다는 취지로 변경하게 되었다. 노동조합의 반발은 보이지 않았으나 그 後 퇴직자가 문제제기를 하여 퇴직금소송이 이어졌다. 그 결과 舊法條項에 대한 效力發生要件說이 확립되기에 이르렀다. 각 판결이유 중의 論據說示가 약간씩 補强되어 왔기에 해당 판시부분을 간추려 두기로 한다.

1976. 7. 13. 선고 75다804 판결 ; "위 平均賃金算定例規는 취업규칙 및 근로조건이 되는 것으로서 노동조합법과 근로기준법 소정의 團體協約이나 勞使協議를 거쳐야만 그 效力을 발행하는 것이다."(同旨 : 1976. 8. 24. 선고 76다1411 판결)

1976. 10. 26. 선고 76다502 판결 ; "同 公社의 平均賃金算定例規를 變更한 것이 勞使協議會의 協議 또는 從業員들의 同意를 거치지 아니한 一方的 措置임이 分明하다면, 이는 위 公社의 賃金規程과 退職金規程, 그리고 團體協約 및 勤勞基準法과 勞動組合法의 關係規定에 비추어 效力이 없다 할 것이다."

1977. 7. 26. 선고 77다355 카 11532 판결 ; "勤勞基準法의 保護法으로서의 精神, 既得權保護의 原則 및 같은 법 제3조,[1] 제98조[2]의 規定 등에 비추어 就業規則의 變更에 의하여 既存 勤勞條件의 內容을 一方的으로 勤勞者에게 不利益하게 變更하려면 從前 就業規則의 適用을 받고 있던 勤勞者集團의 集團意思決定方法에 의한 同意를 要하며 이와 같은 同意가 없는 限 就業規則의 不利益한 變更에 대하여 個人的으로 同意한 勤勞者에 대하여도 그 變更의 效力은 發生되지 아니한다."

1977. 9. 28. 선고 77다681 판결 ; "使用者가 就業規則을 勤勞者에게 一方的으로 不利益하게 變更하려면 從前 就業規則의 適用을 받은 勤勞者集團의 集團意思 決定方法에 의한 同意를 要하고, 그 同意方法은 勞動組合이 있는 경우에는 그 組合의 同意, 組合이 없는 경우에는 勤勞者들의 會合方式에 의한 過半數의 同意이어야 하며 그러한 同意가 없는 限 就業規則變更으로서의 效力을 가질 수 없고, 個人的으로 同意한 勤勞者에 對하여서도 效力이 없다."(同旨 : 1977. 12. 27. 선고 77다1378 판결)

그 反面, 停年이나 人事規則의 변경에 대해서는 柔軟性을 발휘하여 아래 판결과 같이 그 效力을 긍정하는 태도를 보여왔다.

1978. 9. 12. 선고 78다1046 카 11914 판결 ; "停年에 관한 제한규정이 없는 종전의 취업규칙을 변경 함에 있어서 근로자집단의 同意없이 만 55세로 정하는 규정을 새로이 두었다고 해도 違法이 아니다."

1988. 5. 10. 선고 87다카2853 판결 ; "취업규칙의 하나인 人事規程 중 解雇事由 및 任用資格制限事由에 관한 補完 및 變更이 社會通例上 合理性이 있다고 인정되는 限, 근로자에게 불이익한 것이라고 速斷할 수 없는 것이므로 그 변경에 즈음하여 근로기준법 제95조가 정하는 節次를 밟지 아니하였다 하여 그 변경된 人事規程의 效力을 否認할 수 없다."

---

1) 제3조(근로조건의 決定) ; 근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 의하여 결정하여야 한다.

2) 제98조(위반효력) ; 취업규칙이 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효한다. 이 경우에 있어서 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 의한다.
※ 현행 제100조

제95조가 정하는 節次를 밟지 아니하였다 하여 그 변경된 人事規程의 效力을 否認할 수 없다."

Ⅷ. 新法下의 大法院 判例

舊 근로기준법 제95조 제1항에 但書規定(= 부이익변경시의 근로자집단의 同意규정)이 追加(= 新設)된 후(1989. 3. 29.後)에 선고된 판례를 훑어보면, 그 적용사안의 대부분은 舊法下에서 변경이 행해진 취업규칙을 다룬 것이다. 순수한 新法의 적용사안은 아직 찾아보기 힘들다.

여하튼 위 但書의 集團同意規定은 대법원의 既存 判例理論의 成文法化에 지나지 않기 때문에 新法의 적용사안이라고 해서 이론구성을 달리할 필요는 없는 상황에 놓여왔다.

그럼에도 新法下에 선고된 大法院 判例는 그 흐름에 있어서 약간의 柔軟性을 보여나가기도 하고, 때로는 正反對로 더욱 엄격한 效力發生要件說로 되돌아가기도 한다.

가. 訓示規定說과 效力規定說과의 兩立二元論

以上의 判例에서는 舊 근로기준법 제95조 제1항 本文의 意見聽取節次規定 自 가 訓示規定이냐 效力規定이냐에 대하여는 直接的 說示없이 지나쳤었다.

그러다가 위 法條項의 但書規定이 新設된 直後에 나온 1989. 5. 9.선고 88다카4277 판결에 이르서야 위 의견청규규정 자체를 가리켜 "訓示規定에 불과하고 效力規定이 아니므로 이를 거치지 않았다고 하여 그 취업규칙이 無效로 되지는 않으나"라고 說示하였다.

그러고나서는 "既得의 權利나 利益을 剝奪하여 不利益한 勤勞條件을 賦課하는 내용일 때에는 勤勞者集團의 集團意思決定方法에 의한 同意를 요하고, 이러한 同意 없이 作成, 變更된 就業規則은 勤勞條件의 변경이 근로자의 동의를 받지 않아도 社會通例上 合理性이 있다고 인정될 만한 것이 아닌 한 無效이다."라고 해석론을 정비하였다. 이러한 해석론은 결국 위 제95조 제1항 본문은 訓示規定이나 그 但書은 效力規定이다 라는 兩立二元論을 밝힌 셈이며, 이 점에 그 意義가 크다고 사료된다.

그 후 退職金사건에 있어서는 無條件的 無效論을 접어두고서 社會通例上의 合理性 有無라는 잣대를 앞세우는 說示가 등장되어 나갔다.

1992. 11. 27. 선고 92다32357 판결(韓國道路公事 사건) ; "정부투자기관들이 1980년대 초의 어려운 경제여건하에서 보수와 퇴직금을 일반 공무원들보다 훨씬 높은 수준

으로 지급하여 財政難을 겪는 등 不合理한 運營을하여 왔으므로 이를 是正하기 위하여 政府의 方針에 따라 退職給與規程을 직원들에게 불이익하게 개정한 것이라 하더라도 근로자집단의 同意를 받지 않아도 될 만한 社會通念上의 合理性이 있다고 인정되지 아니한다. 직원들이 異議없이 퇴직금을 受領하여오고, 퇴직급여규정 改正 以後 결성된 노동조합과 사용자사이에 단체협약을 체결하면서 團體協約에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 사용자측의 關係規程에 따르기로 하였다는 등의 사정만으로 無效인 퇴직급여규정의 改正을 追認한 것으로 볼 수 없다."

나. 新 · 舊 就業規則의 併存論

다른 한편, 1992. 12. 22. 선고 91다45165 全員合議體 판결(江原産業 회사 사건)은 일방적 불이익변경의 無效인 就業規則일지라도 그 변경후의 新規入社者에게는 그 效力을 갖는다고 판단함으로써 相對的 有效說(= 新 · 舊併存說)을 채택하게 되었다.

즉, 위 전원합의체 판결은, "使用者가 就業規則에서 정한 勤勞條件을 勤勞者에게 불리하게 變更함에 있어서 勤勞者의 同意를 얻지 않은 경우에 그 變更으로 既得利益이 침해되는 既存의 勤勞者에 대한 관계에서는 變更의 효력이 미치지 않게 되어 從前 就業規則의 효력이 그대로 유지되지만, 變更 후에 變更된 就業規則에 따른 勤勞條件을 수용하고 勤勞關係를 갖게 된 勤勞者에 대한 관계에서는 당연히 變更된 就業規則이 적용되어야 하고, 既得利益의 침해라는 效力排除事由가 없는 變更 후의 就業勞動者에 대해서까지 變更의 효력을 부인하여 從前 就業規則이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다."

※ 이로써 絶對的 無效說을 취했던 90. 4. 27. 선고 89다카7754 판결, 90. 7 .10. 선고 89다카31443 판결, 91. 12. 10. 선고 91다8777 · 8784 판결은 폐기되었다.

다른 한편, 退職金規程의 불이익변경에 대해서는 事後追認理論의 적용에 있어서도 如前히 否定的 태도를 견지해 나갔다.

1995. 7. 11. 선고 93다26168 全員合議體 판결(大韓住宅公社 사건) ; "퇴직급여규정이 勤勞者集團의 同意 없이 불이익하게 변경된 以後에 설립된 노동조합이 회사와 團體協約을 締結하면서, 시행중인 취업규칙이 無效인 사정을 모른 채 단체협약附則에 "협약에 明示되지 아니한 사항은 관계 법령 및 관행에 따르기로 한다."는 규정을 둔 것만으로는, 무효인 위 퇴직급여규정의 개정을 追認한 것으로 볼 수 없다."

다. 事情變更理論의 導入 ; 無效規則의 事後轉換

다른 한편으로는 無效行爲의 事後轉換理論을 방불케하는 판례를 확립시켜 나갔다. 즉, 취업규칙의 改正當時에는 일방적 不利益變更의 無效이었던 것이 그 後의 事情變更에 의하여 그 無效인 취업규칙이 근로자들에게 보다 有利하게 된 때에는 그 때부터는 有效한 취업규칙으로 轉換되어 이를 적용하여야 한다는 판례가 확립된 것이다.

1997. 8. 26. 선고, 96다1726 판결(韓國證券電算 회사 사건)

1999. 12. 28. 선고, 99다3382 판결(農協中央會 사건)

그 반면, 停年制의 導入에 관하여는 從前 판례(1978. 9. 12. 선고, 78다1046 카 11914 판결)의 有效論과는 달리 無效說을 취한 것이 있다.

1997. 5. 16. 선고. 96다2507 판결(흥인운수회사 사건) ; "취업규칙의 변경이 사회통념상 합리성이 있느냐의 여부와 근로자에 불이익 하느냐의 여부는 그 변경의 취지와 경위, 해당 사업체의 業務의 性質, 취업규칙 각 규정의 全體的인 制 등 제반사정을 종합하여 판단하여야 한다. 停年規定의 신설로 인하여 만 55세로 停年에 이르고 회사의 심사에 의하여 일정한 경우에만 만 55세를 넘어서 근무할 수 있도록 되었다면 旣得의 權利나 利益을 박탈하는 불이익한 근로조건을 부과하는 것에 해당한다."

라. 社會通念上의 合理性을 肯定한 판례등장

退職金規程의 일방적 불이익변경에 대하여는 보다 高度의 사회통념상의 합리성을 是認할 수있어야 된다는 判例의 기나긴 흐름은, 아래 判決 2건에 의하여 그 合理性을 肯定하게 된 듯싶다. IMF 經濟危機를 맞이한지 4 · 5年次에 結實을 맺기에 이른 判例法理로서 그 意義가 큰 듯 싶다.

2001. 1. 5. 선고, 99 다70846 판결(재단법인 韓國機械硏究院 퇴직금 사건)

2002. 6. 11. 선고, 2001다16722 판결(재단법인 韓國衣類試驗硏究院 퇴직금사건)

後者의 判決은 主題의 對象判決로서 앞에서 수록한 바 있으며, 前者의 判決은 그 法理說示部分은 後者의 경우와 꼭 같으므로 그 소개를 생략키로 하고, 具體的判斷說示部分만을 이 곳에 옮겨두기로 한다.

" 원심판결 이유에 의하면, 原審은 그 판결에서 채용하고 있는 증거들을 종합하여 그 판시의 사실을 인정한 다음, 재단법인 한국기계금속시험연구소의 1980.

3 .6. 퇴직금지급규정이 재단법인 한국정밀기기센터(이하 '한국정밀기기센터'라고만 한다)의

1970. 1. 1. 퇴직금지급규정에 비하여그 支給率에 있어서 不利益한 것은 사실이나,

① 한국기계금속시험연구소의 1980. 3. 6. 퇴직금지급규정을 제정할 당시 한국정밀기기센터 출신 직원들과 기존의 한국기계금속시험연구소 직원들 사이에 서로 다른 退職金支給率을 調整하고, 統一的인 퇴직금지급규정을 마련할 必要性이 높았던 점,

② 한국정밀기기센터 출신 직원들의 停年이 통합 후 55세에서 65세로 10년이나 延長됨에 따라 연장된 期間만큼 더 근무하면서 이에 상응하는 임금을 지급받게 된 점,

③ 통합을 전후하여 한국정밀기기센터 출신직원들의 賃金이 引上되고, 號俸이 조정됨에 따라 퇴직금 산정의 기초가 되는 임금이 인상되는 등 統合後 다른근로조건이 改善되었고, 이로써 퇴직금지급률의 저감에 따른 不利益이 상당정도 緩和된 점,

④ 통합에 앞서 원고를 포함한 한국정밀기기센터 출신 직원들이 한국정밀기기센터를 形式的으로 退職하면서 引上된 賃金을 기초로 종전의 높은 퇴직금지급률에 의한 퇴직금을 異議없이 수령하였고, 따라서 통합 당시에는 원고를 포함한 한국정밀기기센터 출신 직원들도 향후 제정될 한국기계금속시험연구소의 퇴직금지급규정이 자신들에게 적용될 것으로 豫想하고 있었다고 추정되는 점 등의 제반 사정에 비추어 볼 때,한국기계금속시험연구소의 1980. 3. 6. 퇴직금지급규정은 한국정밀기기센터 출신직원들의 집단적 의사결정방법에 의한 同意를 받지 않아도 될 만한 社會通念上의 合理性이 있었다고 봄이 상당하고, 따라서 이는 원고를 포함한 한국정밀기기센터 출신 직원들에게도 적용된다고 판단하고 있다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 原審의 위와 같은 판단은 수긍이 가고, 거기에 사회통념상의 합리성 유무에 관하여 법리를 오해하였거나 그에 관하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유가 들고 있는 대법원 1995. 12. 26. 선고 95다41659 판결은 취업규칙의 변경과 관련한 사회통념상의 합리성 유무에 관하여 어떠한 判斷을 한 것은 아니므로 원심이 대법원판례와 상반되는 판단을 하였다고 할 수도 없다. 이 부분 상고이유는 모두 받아들일 수 없다."

Ⅸ. 서울地方辯護士會의 判例硏究資料

취업규칙의 불이익 변경에 관계되는 서울지방변호사회의 判例硏究發表는 몇차례 이어져왔다.

1991. 7. 10. 변호사 崔 明 圭 ; 근로자에게 불이익한 취업규칙 변경의 요건[2)]
대법원 1991. 4. 9. 선고 90다16245 판결

1996. 3. 20. 변호사 黃 秉 一 ; 퇴직금규정이 변경된 경우 그 유효요건[3)]
대법원 1995. 10. 13. 선고 95도1761 판결

1999. 3. 24. 변호사 張 元 燦 ; 경영위기하의 상여금 지급중지의 효력[4)]
대법원 1999. 6. 11. 선고 98다22185 판결

2000. 11. 1. 변호사 金 光 年 ; 퇴직금제도변경에 있어서 기득권이익보호를 위한 경과규정의 효력[5)]
대법원 1999. 12. 28. 선고 99다33823 판결

2002. 4. 17. 변호사 黃 秉 一 ; 회사 합병 후의 퇴직금규정 변경의 효력[6)]
대법원 2001.10. 30.선고 2001다24051 판결

Ⅹ. 反省 · 討議를 요하는 側面

퇴직금지급률은 牽制勢力이 워낙 弱한 탓으로 고삐풀린 말(馬)처럼 소리없이, 야금야금, 손쉽게 引上되어 나가기 마련이었다. 이는 類似한 기업 · 단체 · 금융기관 등으로 傳播되어 나가기 마련이었다. 그래서 이른바 軍事政府下의 혈기왕성하고 정의감이 넘치던 세력은 두차례(1970년대 초반 및 1980년도)에 걸쳐 퇴직금지급률의 下向調整을 强力히 독려 · 지시하게 되었다.

이때 國民輿論도 박수갈채를 보내던 터라서 그 下向調整作業은 순조롭게 달성된 듯싶었다. 다만, 근로자집단의 同意節次를 밟지 않았는데, 그 당시로서는 그 判例法理(=效力發生要件說)를 깨다지 못해서 지나쳤던 것이다. 만약 이 判例法理를 누군가가 알려주었더라면, 그 同意節次쯤이야 얻어내기는 쉬운상황(공포분위기?)이었다.

---

2) 서울지방변호사회 ; 判例硏究 제 5 집 371쪽이하, 1992. 1. 25. 발행
3) 〃 ; 〃 제10집 342쪽이하, 1997. 1. 25. 발행
4) 〃 ; 〃 제13집 226쪽이하, 2000. 1. 20. 발행
5) 〃 ; 〃 제14집 246쪽이하, 2001. 1. 27. 발행
6) 〃 ; 〃 제16집(上) 248쪽이하, 2002. 8. 26. 발행

여하튼, 위 不利益 更을 행한 결과, 사후에 초래된 判決의 결론은 既存 勤勞者에게는 그 效力이 미치지 못하여 從前 規則을 적용해야 하고, 새 規則은 오직 新規入社者에게만 그 效力을 갖게 되었다(1992. 12. 22. 선고 91다45165 全員合議判決). 그리하여 하나의 사업장, 하나의 근로조건에 있어서도 退職金算定基準의 높낮이가 다양하게 분포하는 현상이 생기고 말았다. 이는 취업규칙 本來의 統一的 · 劃一的 性質과는 동떨어지는 현상이다. 그래서 統一努力을 경주해 보았겠지만 어느 體制로 統一할 것이냐?의 신경전에서도 기존 勤勞者측이 양보할 리는 만무하다. 결국 使用者측이 양보하는 통일(= 原狀復歸)이 되고 만다.

결국, 위 法條項에 따라 근로자측의 集團同意를 받아내는 일은 과연 現實性을 期待할 수 있는 것인가? IMF 경제위기하의 경험을 통해서도 위 條項은 현실성이 缺如된 理想論에 불과함이 입증되어 왔다. 그렇다면 判例法理는 또 한차례 解決策을 모색 해나가야 되리라고 생각해 본다. 이 지경에 이르고 보면, 既發生된 既得權과 未來의 既得權과의 사이에 保護强度의 差異法理를 도입했으면 하는 바람을 느끼게 된다. 근로계약이나 단체협약의 有效期間條項과의 연결해석도 기대하게 된다.

【發表日時 : 2002. 9. 18. (수) 07:30 司會者 : 金鎭興 辯護士】